

1501473-44.2021.8.26.0540

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, que o agravante se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501473-44.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2178331/2021 - 04º D.P. MAUA, 18828667 - 04º D.P. MAUA, AC9325-1/2021 - 04º D.P. MAUA, 2178331 - 04º D.P. MAUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS GONÇALVES PAES DA SILVA

Data da Audiência:

24/05/2022

Justiça Gratuita

Em 24 de maio de 2022 às 15h10, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório.

Presente o réu Jonas Gonçalves Paes da Silva. Presente o Advogado, Dr. Wellington Almeida Souza (OAB 205.936/SP). Presentes as testemunhas comuns Severino de Moraes e Douglas Anderson Dias. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, foram inquiridas as testemunhas, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelo Ministério Público foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Severino, o que foi homologado pelo MM, Juiz. Pela defesa foi manifestada a insistência em ouvi-lo; a testemunha foi ouvida (gravação audiovisual). A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, pela defesa foi reiterada manifestação de fls. 155, quanto a juntada do depoimento do menor Kaique, prestado na Vara da Infância e Juventude. O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao requerido pela defesa. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "1) Inicialmente, indefiro o pedido de juntada da oitiva informal do adolescente Kaique (fls. 154/155), porque houve preclusão, já que não houve este requerimento na defesa preliminar (fls. 132/133). O fato de o réu ter constituído defensor não repristina os atos processuais já praticados. 2) Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. JONAS GONÇALVES PAES DA SILVA, qualificado às fls. 5/6 e 31 = 84, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, porque, no dia 01 de julho de 2021, por volta das 14h:35min, na Rua Lourival Portal da Silva, nº 336, Jardim Zaira, nesta cidade e comarca de Mauá, previamente ajustado e agindo em unidade de desígnios com a adolescente Kaique Perbuaire Silva Pereira, traziam consigo e guardavam, para entregar a consumo de terceiros, drogas consistentes em 36 eppendorfs de crack, com peso líquido de 4,3g, 61 invólucros de cocaína, com peso líquido de 40,3g, e 72 invólucros de maconha, com peso líquido de 97,2g, e 22 tubos de lança-perfume, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 21/23, e laudos químico-toxicológicos de fls. 99/101 e 109/115 (fls. 120/121). Foi concedido ao acusado o benefício da liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares (fls. 67/69). A denúncia foi oferecida (fls. 119). O réu foi notificado (fls. 127) e apresentou defesa preliminar (fls. 132/133 e 154/155). A denúncia foi recebida e foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 134/139). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Douglas Anderson Dias (gravação audiovisual) e Severino de Moraes (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Jonas Gonçalves Paes da Silva (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foi ouvida a testemunha Douglas Anderson Dias (fls. 2 = 32), o réu Jonas Gonçalves Paes da Silva (fls. 5/6), o adolescente Kaique Perbuaire Silva Pereira (fls. 11), e a testemunha Severino de Moraes (fls. 16). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Jonas, em debates, requereu a improcedência da ação (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1). Auto de exibição e apreensão (fls. 19/20). Laudo de constatação provisória (fls. 21/23). Laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls.

99/101 e 109/115). Folha de antecedentes (fls. 123) e certidão (fls. 38/39). II - Fundamentação. A ação penal é parcialmente procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), laudo de constatação provisória (fls. 21/23), laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls. 99/101 e 109/115) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. A testemunha Douglas Anderson Dias, sob o crivo do contraditório, disse que: a) o local é conhecido por mim e o meu parceiro como ponto de venda de drogas; b) fomos com viatura descaracteriza, paramos já uns 50 metros, vimos o adolescente Kaique chegar até o Jonas, daí o Kaique voltou, deu algo ao Jonas que manuseava algo; c) a mochila estava nas costas do Jonas; d) havia aproximadamente entre 190 a 200 invólucros de entorpecentes; e) o Jonas disse que receberia 10% das vendas dos entorpecentes e o adolescente infrator receberia para abastecer ele; f) havia maconha, cocaína e crack, entre 190 a 200 porções entre o que estava no interior da mochila e o que ele recebeu do Kaique; g) o Kaique disse que foi pegar os entorpecentes para abastecer o Jonas; h) não me recordo se havia mais pessoas com o réu e o menor; i) eu e o meu parceiro abordamos os Jonas e no colo dele ele há manuseava os entorpecentes; j) nós pedimos para o Jonas, mandamos ele levantar a camisa e ele tinha a mochila; k) não me recordo do réu e do adolescente tínhamos notícias dele de um fato anterior ou posterior à prisão; l) não tenho nada contra o réu ou o adolescente; m) Severino de Moraes tem as mesmas informações que eu (gravação audiovisual e fls. 2 = 32). Em juízo, a testemunha Severino de Moraes disse que: a) o local onde foi feita a prisão do Jonas já é conhecido por termos feito outros flagrantes de entorpecentes; b) fomos ao local com viatura descaracterizada; c) vimos duas pessoas conversando e uma delas nas costas; d) depois de um tempo chegou o Kaique com um sacola para o Jonas; e) o adolescente saiu e entrou em um comércio; f) abordamos o Jonas e na sacola e na mochila havima entorpecentes; g) depois o menor saiu do comércio e foi abordado; h) o Jonas disse que vendia entorpecentes e ganharia 10% das vendas; i) o adolescente disse que abastecia o Jonas; j) eu revistei o Jonas; k) fomos ao local, porque há denúncias, ainda há denúncias até hoje; l) nenhuma denúncia vinha com o nome do Jonas, mas havia denúncias com o nome do adolescente Kaique; m) a sacola e a mochila que estavam os entorpecentes, estavam com o Jonas, o maior de idade; n) havia cocaína, maconha, crack e lança-perfumes, aproximadamente 180 porções e entre R\$ 80,00 a R\$ 90,00; o) não conhecia o réu; p) o adolescente eu já conhecia, porque havia outras denúncias contra o adolescente Kaique; q) não tenho nada contra os dois (gravação audiovisual e fls. 16). Por fim, o réu Jonas Gonçalves Paes da Silva, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) as drogas estavam na mochila, mas eu não sabia que na mochila; b) a mochila estava comigo; c) o Kaique me deu a mochila e subiu; d) em questão de 30 minutos, ele voltou, mas a blusa de frio dele estava com volume e eu falei se não tá aprontando Kaique; c) chegou um Palio bem devagar; d) quando eu segurei a bolsa para o Kaique, eu somente sabia que o Kaique fuma maconha; e) eu não tinha drogas no meu colo, eu somente tinha um refrigerante no meu colo, eu somente segurei a mochila; f) eu tinha dois amigos comigo (gravação audiovisual e fls. 5/6). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), laudo de constatação provisória (fls. 21/23), laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls. 99/101 e 109/115), como também pela declaração do adolescente Kaique Perbuaire Silva Pereira (fls. 11), e pelos depoimentos das testemunhas Douglas Anderson Dias (gravação audiovisual e fls. 2 = 32) e Severino de Moraes (gravação audiovisual e fls. 16), e pela autodefesa do réu (gravação audiovisual e fls. 5/6), foi comprovado que as testemunhas,

que são policiais civis, realizavam diligências no local dos fatos, que é conhecido como ponto de venda de drogas, quando viram o réu Jonas com uma mochila nas costas e o adolescente veio até ele, saiu, voltou e entregou-lhe uma sacola. Então, abordaram o réu e na sacola e na mochila que estavam com ele havima 36 eppendorfs de crack, pesando 4,3g, 61 porções de cocaína, pesando 40,3g, e 72 porções de maconha, pesando 97,2g, e 22 tubos de lança-perfume, como também a quantia de R\$ 90,00. A autodefesa do réu restou isolada nos autos, não sendo o caso da desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, em decorrência da

"natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente" (artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006), conforme já fundamentado. Contudo, não reconheço a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006, pois não foi apresentado documento do adolescente Kaique Perbuaire Silva Pereira, conforme ficou estabelecido no Tema nº 1.052 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Jonas Gonçalves Paes da Silva, pela prática do crime de tráfico de drogas envolvendo adolescente, previsto no 33 da Lei 11.343/2006. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (36 eppendorfs de crack, pesando 4,3g, 61 porções de cocaína, pesando 40,3g, e 72 porções de maconha, pesando 97,2g, e 22 tubos de lança-perfume - fls. 19/20, 21/23, 99/101 e 109/115) não permitem aumentar a pena, e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 38/39 e 123). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas. Deixo de reduzir a pena do réu, em decorrência da sua menoridade (fls. 1 e 5/6), porque ela já se encontra no mínimo legal e não pode ficar aquém do mínimo nesta fase de dosimetria da pena, nos termos do artigo 67 do Código Penal e Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase de aplicação da pena, não há aumento a pena. Reduzo a pena em 2/3, passando para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 194 dias-multa. Ressalto que entendo que poderia me utilizar da natureza e da quantidade das drogas, para fins de obstar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Contudo o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 712, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.887.511/SP, passaram a entender que não é possível a utilização da natureza e da quantidade das drogas na terceira fase de aplicação da pena. Outrossim, não há outro critério para a redução da pena entre 1/6 e 2/3, a não ser a natureza e a quantidade das drogas, mas, como já dito, ela não pode ser utilizada na terceira fase da dosimetria da pena, por esta razão reduzi a pena no máximo de 2/3, pois, não havendo outro critério a ser utilizado, e não há, o juiz não poderia quantificar a pena a seu bel-prazer, pois agindo assim estaria violando o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Inclusive, nos processos nos 1500527-09.2020.8.26.054 (fls. 318/325) e 1501072-79.2020.8.26.0540 (fls. 426/435), que tramitam nesta Vara, foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça que este magistrado recalculasse a pena com base nestes parâmetros. Desta maneira, por segurança das relações jurídicas, passo a dosar a pena, conforme a mencionada orientação dos Tribunais Superiores. No caso do tráfico de drogas, o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 determina que o juiz "na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente" - (grifei). Ou seja, a fixação da pena compreende a dosimetria e o regime inicial de cumprimento, tanto que o legislador ressaltou que a natureza e a quantidade das drogas e a conduta social preponderam sobre o artigo 59 do Código de Processo Penal, e este artigo (59 do Código de Processo Penal) deve ser considerado na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, conforme prevê o artigo 33, § 3º, do Código de Processo Penal. Desta maneira, fixo o regime inicial de cumprimento da pena semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, a despeito de a pena ser inferior a quatro anos e o réu não ser reincidente (fls. 38/39 e 123), a natureza e quantidade das drogas apreendidas (36 eppendorfs de crack, pesando 4,3g, 61 porções de cocaína, pesando 40,3g, e 72 porções de maconha, pesando 97,2g, e 22 tubos de lança-perfume - fls. 19/20, 21/23, 99/101 e 109/115), preponderam sobre o artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, e o artigo 59 do Código Penal deve ser levado em consideração na dosimetria da pena, segundo preceitua o artigo 33, § 3º, do Código Penal. Neste sentido a jurisprudência: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENA E RECUSA DE ENVIO À PGJ. RECUSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO PARQUET. ANUÊNCIA DO MAGISTRADO. PROPOSTA

DE REVISÃO REQUERIDA A DESTEMPO PELA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FÉLIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe de 3/4/2018. 2. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos. Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 4. Conforme o acórdão ora impugnado, o requerimento de revisão do não oferecimento de proposta do ANPP, para fins de análise do órgão superior do Ministério Público local, ocorreu a destempo pela defesa, deixando que a instrução criminal fluísse regularmente. 5. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. No caso, embora estabelecida a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão, a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos (16 porções de maconha, pesando 66,2 gramas; 44 porções de cocaína, pesando 39,6g; 33 porções de crack, pesando 7,1g; - 13/16 e 70/71) , utilizadas na escolha do patamar de diminuição do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, o semiaberto, em razão da quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos. 7. Habeas corpus não conhecido.” - (grifei). (HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020). “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSIÇÃO JUSTIFICADA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte a quo afastou a

aplicou a minorante considerando as circunstâncias fáticas da causa, qual seja, a quantidade e variedade das drogas apreendidas. Entender de forma diversa exigiria,

necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. A quantidade e natureza das drogas apreendidas - 116 porções de maconha- constituem fundamentos idôneos para o agravamento do aspecto qualitativo da pena, ou seja, para a fixação de regime mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Tendo a reprimenda ultrapassado os 4 anos de prisão, a circunstância judicial desfavorável (quantidade da droga) justifica a fixação do regime inicial semiaberto, segundo a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.” - (grifei). (AgRg no AREsp 1671723/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressaltados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. III - Ademais, a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta requer fundamentação específica, baseada em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. IV - No caso, aplicada a pena de 2 anos de reclusão, entendo que deve ser estabelecido o regime inicial intermediário, nos termos do art.33, § 3º, do Código Penal, e do art.42 da Lei de Drogas. A quantidade e variedade dos entorpecentes podem ser utilizadas como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06. V - O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o HC n. 97.256/RS, reconhecendo a inconstitucionalidade da parte final do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, passou a admitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. VI - Na hipótese em análise, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (16 porções de maconha, pesando 66,2 gramas; 44 porções de cocaína, pesando 39,6g; 33 porções de crack, pesando 7,1g; - 13/16 e 70/71) não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consoante o disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na negativa da benesse em tela. Habeas corpus não conhecido. Ordem de ofício apenas para fixar o regime semiaberto para resgate da reprimenda, mantido os demais termos da condenação.” - (grifei). (HC 581.356/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020). “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO ADEQUADO. AFASTAR CARÁTER HEDIONDO. PLEITO PREJUDICADO. DETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Concluído pelas instâncias antecedentes, com fulcro nos elementos constantes dos autos e no fato de registrar atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, que o agravante se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir

a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. 4. Embora o agente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento das sanções impostas, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade e natureza de entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 5. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão, é inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 6. Fica prejudicado o pleito de afastamento do caráter hediondo do delito, pelo não reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado. 7. Noticiado o trânsito em julgado da ação penal, caberá ao Juízo de execução penal averiguar a possibilidade de estabelecimento de regime mais brando diante do desconto do período em que o agravante permaneceu preso preventivamente. 8. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 573.149/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020) - (grifei). Não substituo a pena do réu, porque, nos termos do artigo 44, § 3º, do Código Penal, não é socialmente recomendável, pela natureza e quantidade das drogas (36 eppendorfs de crack, pesando 4,3g, 61 porções de cocaína, pesando 40,3g, e 72 porções de maconha, pesando 97,2g, e 22 tubos de lança-perfume - fls. 19/20, 21/23, 99/101 e 109/115), fato concreto que impede a substituição. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 5/6). Igualmente, determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 19/20), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, determino, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (19/20, 21/23, 99/101 e 109/115). III - Em razão do exposto, CONDENO o réu JONAS GONÇALVES PAES DA SILVA (R.G. nº 59.682.493 - filho de Odair Paes da Silva e Patricia Gonçalves Sardinha - fls. 5/6 e 31 = 84), pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 166 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais ele aguardou todo o trâmite processual solto (fls. 67/69). O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; b) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; c) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; d) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." Pela defesa e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo a apelação interposta pela Defesa e pelo réu. Aguarde-se a apresentação das razões no prazo legal. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ),

sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline
Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.